

1500281-94.2021.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500281-94.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-94.2021.8.26.0631

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247064/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20171359 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 1494/21/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2247064 - DEL.POL.SERRA

NEGRA, 2247064 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 1494/21/112 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RAFAEL ANDRADE DA SILVA

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

LUAN RAFAEL ANDRADE DA SILVA, vulgo "Talibã", devidamente qualificado nos autos (fl. 17), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Maria Roza Federice, 168, via pública, Parque Modelo, nesta cidade e Comarca, sido surpreendido trazendo consigo,

para fins de comercialização, 15 (quinze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 9,55g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular (fls. 96/97).

Em audiência de custódia o acusado foi ouvido e sua prisão flagrancial convertida em flagrante (fls. 55/58).

Por força de decisão exarada em habeas corpus julgado pelo E. TJSP, foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fl. 110). Alvará de soltura cumprido (fls. 122/125).

A denúncia foi recebida em 30.09.21 (fl. 99).

O réu foi citado (fls. 103) e, por intermédio de seu D. Defensor (fl. 108), apresentou resposta por escrito à acusação (fl. 131), arrolando testemunhas comuns.

Não sendo o caso de julgamento in limine, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura de instrução probatória (fl. 135), ocasião em que foi colhida prova oral, consistente nas oitivas das duas testemunhas arroladas em comum, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 162).

O réu não foi interrogado, porquanto revel (fl. 162).

Encerrada a instrução, em sede de memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu por entender suficientemente comprovadas autoria e materialidade (fls. 151/153).

A D. Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando-a na fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação original para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06), sustentando a condição de mero usuário (fls. 154/160).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração está devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação provisória (fls. 14/15), ilustrado pela fotografia de fl. 16, importe numerário apreendido (fl. 84) e, principalmente, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado nas substâncias entorpecentes (fls. 102/104), que confirmou tratar-se de cocaína, substância que causa dependência física ou psíquica listada na Portaria nº 344/98 - SVS/MS.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que o réu foi preso em flagrante, surpreendido trazendo consigo entorpecentes, cujas circunstâncias fáticas, quantidade e forma de armazenamento indicam destinação ao tráfico ilícito, razão pela qual a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos depoimentos colhidos no caderno investigativo e

produzidos sob o crivo do contraditório autoriza concluir pela responsabilidade penal do acusado. Vejamos.

O guarda municipal Luiz Antonio Splendore relatou que na data dos fatos a base da GCM recebeu uma "denúncia" noticiando a ocorrência de tráfico no terminal rodoviário do São Dimas, por um indivíduo, com certas características vestimentais (calça e moletom na cor preta). Então, para lá se dirigiu, desembarcou à pé da viatura e visualizou o réu, com as mesmas características recebidas, que ao notar sua presença no local se evadiu, vindo a arremessar, no trajeto, objetos no interior de uma obra, posteriormente identificados, pelo depoente, como sendo 15 papелotes de cocaína e R\$10,00. Abordado, em poder dele foram localizados aproximadamente R\$200,00 em dinheiro.

Silente em solo policial (fl. 06), LUAN não foi interrogado em juízo, porquanto, solto, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, descumprindo sua obrigação, não sendo localizado para intimação, apresentando-se, pois, revel (fl. 162).

Pois bem. Este é o contexto probatório que acena para a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Vejamos.

O guarda municipal bem destacou o recebimento pela GCM, momentos antes, de "denúncia" veiculando a prática da traficância no terminal rodoviário do Bairro São Dimas, por um indivíduo trajando calça e moletom pretos. Então, para lá se dirigiu com seu parceiro, desembarcando da viatura e visualizando LUAN, com as mesmas características transmitidas, sendo que este, ao notar a presença dele no local, tentou fugir, arremessando durante o trajeto algo na direção do interior de uma obra, posteriormente identificado como sendo 15 papелotes de cocaína. O réu foi perseguido, alcançado e abordado, estando em poder de aproximadamente R\$200,00 em dinheiro.

O policial frisou ter visto o movimento corporal esboçado pelo réu, ao tempo em que se desfez das drogas que trazia consigo, bem como localizado os entorpecentes no interior de um obra, local em que foram dispensados.

Ademais, junto com aqueles entorpecentes apreendidos e em poder do réu foram encontrados certos valores em dinheiro, sem qualquer demonstração da origem lícita (fl. 84).

Então, as circunstâncias geográficas e temporais, além da reação corporal apresentada, indicam estar o réu naquele local para venda, não sendo comum usuários ali permanecerem, com drogas naquela quantidade e forma de acondicionamento (todas embaladas individualmente: foto de fl. 16), prontas para comercialização e, ainda, em poder de considerável valor em espécie, expondo-se à abordagem policial, eis que o local é conhecido "ponto" de venda.

É certo que a prova oral colhida durante a instrução baseia-se, principalmente no depoimento dos policiais que realizaram a investigação criminosa, mas, vem sendo pacificada na repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto a alegação de imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que participam da diligência que culmina com a apreensão de entorpecentes.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, destinada a neutralizar o esforço até patriótico na luta contra as drogas, em recalcitrar, atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse

alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverossimilhança ou o entrechoque com outras provas.

Então, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais que efetuaram o diligenciamento criminoso, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação.

Destarte, inviável o pedido de absolvição, sobretudo devido a quantidade e forma de embalagem das drogas, bem como das circunstâncias fáticas-criminosas em que o réu estava inserido.

É certo que o fato de não ter sido preso "vendendo" a droga é matéria irrelevante para a configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência torrencial a respeito, pois o entendimento francamente vencedor é no sentido de que o perigo de dano em tais casos é presumido de modo absoluto, tendo em vista o perfeitamente conhecido efeito lamentável causado pelo traficante de drogas.

É evidente que o tráfico de entorpecentes envolve atividades essencialmente clandestinas, daí a razão da não exigência da prova flagrancial do comércio ilícito, mas elementos, concretos, que forneçam a evidência do comércio.

Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial desde a época da Lei 6.368/76:

"Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (hoje 33, caput, da Lei 11.343/06), não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição para consumação do delito" (TJSP - RL. Des. Denner de Sá - RJTJESP vo. 97/512).

Outrossim, já se decidiu que "para formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente..." (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, APL n. 21.376, Rel. Ernani Ribeiro - "JC", vol. 53/464).

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo se falar em desclassificação para o crime de porte (artigo 28, caput, da Lei 11.343/06), pena de se afrontar à prova dos autos e a boa atuação dos policiais.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no artigo 59, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o acusado é primário e não contava com antecedentes conhecidos à época dos fatos (fl. 149).

De outra parte, inexistem, a meu sentir, circunstâncias judiciais que exijam a majoração nesta fase, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, eis que o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime, cuja redução de 1/6 (um sexto), todavia, resta prejudicada, em razão da pena já estar em seu patamar mínimo (Súmula nº 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Os requisitos (cumulativos) para

aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado.

Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levado em conta a quantidade das substâncias apreendidas.

Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade de droga e o campo de comercialização delas, menor a diminuição da pena.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09).

Nesta esteira, considerando a natureza do entorpecente, seu campo de comercialização e a quantidade é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/2 (metade).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Mesmo conhecedor do recente posicionamento do C. STF exarado no HC 118.533 (23.06.16) decidindo não ser o “tráfico-privilegiado” de natureza assemelhada ao crime hediondo, é posicionamento deste julgador que o caso em apreço reclama a imposição de regime INICIAL FECHADO.

Cabe invocar ensinamento daquela mesma Corte Suprema: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59” .

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua, mormente frente ao seu retorno precoce à sociedade, com a sensação de Justiça banalizada.

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime

mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP .

NÃO há que se falar em aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu LUAN RAFAEL ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se desconhece que em 01.09.2010 o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes regulados na Lei Federal nº 11.343/2006. O emblemático leading case coube ao "Habeas Corpus" nº 97.256, impetrado pela Defensoria Pública da União no município de Porto Alegre-RS.

Também não passa despercebido que o Senado Federal, recentemente, promulgou no dia 15 de fevereiro a Resolução nº 05 de 2012, suspendendo, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Todavia, salvo raríssimas e excepcionais situações, a condição de traficante inviabiliza o agraciamento do agente com a substituição em voga, pois o comercializador de drogas, desprovido de senso moral, destruidor de lares e famílias, não preenche os requisitos subjetivos estampados em lei.

O tráfico de drogas apresenta lucros incalculáveis e prejuízos incontáveis à ferida sociedade, tratando-se de mercancia vil, de intensa potencialidade lesiva para a saúde pública e para a sociedade.

Tal constatação vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, exigido, cumulativamente a outros, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nesse sentido:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ªT, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Aliás, bem ressaltou o Eminentíssimo Desembargador Ricardo Tucunduva, "...o tráfico de drogas é delito incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país..." (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal, Ap. nº 0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.12).

E, ainda, sobre a índole e personalidade de pessoas voltadas para o comércio ilícito de substância entorpecente atentemo-nos para o fato de que o "... traficante de entorpecente é indivíduo desprovido de sensibilidade ética-moral, guiando-se apenas pelo lucro fácil, arrastando para o mal milhares de jovens, contribuindo para a deterioração da saúde alheia, levando desespero e trauma aos familiares desses jovens. Lares são destruídos, sequelas enormes não somente nos jovens atingidos pelas garras desses impiedosos traficantes, como também a seus genitores .

Ademais, não nos parece ter sido a intenção precípua do Poder Constituinte Originário conceder beneplácitos a crimes equiparados aos hediondos, cujo tratamento jurídico merece maior rigorismo.

A meu sentir, respeitado judicioso entendimento em sentido contrário, seria ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos ou equiparados a eles, sob pena de se esvaziar o tratamento mais rígido que a Lei buscou imprimir, fortalecendo a política criminal voltada a inibir a mercancia espúria de estupefacientes, que, a propósito, propaga sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país, notadamente de índole patrimonial.

LUAN teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva, conforme decisão de fls. 55/58, mas solto por força de decisão colegiada, não unânime, do E. TJSP, ao tempo do julgamento do habeas corpus impetrado (fl. 110).

Por ocasião da sua soltura, declinou um endereço (fl. 125) junto ao qual não foi localizado pessoalmente para ser intimado (fl. 142), porquanto se mudou sem comunicar o Juízo, estando, portanto, em local incerto e não sabido, vivendo nas ruas, conforme relato dos próprios familiares.

Entendo, dessa forma, que adotou postura descompromissada para com o Poder Judiciário, que lhe concedeu um voto de confiança, deixando de informar seu paradeiro atualizado e comparecer em juízo.

Outrossim, nessa data, suportou decreto condenatório, a ser cumprido em regime prisional mais gravoso, sem espaço para benefícios alternativos, na visão deste Julgador.

Assim, a fim de garantir a ordem pública e, principalmente, assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto - principalmente frente ao relatado pelos familiares (fl. 142) -, REVOGO a liberdade provisória e, presentes requisitos e fundamentos da custódia cautelar (art. 312, caput e §2º, do CPP), DECRETO sua PRISÃO PREVENTIVA, vedando-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Expeça-se imediato mandado de prisão.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos importes numerários apreendidos (fl. 84) em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução (Súmula nº 716 do STF), anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA